第 29 卷第 10 期　　商丘师范学院学报　　Vol. 29　No. 10
2013 年 10 月　　JOURNAL OF SHANGQIU NORMAL UNIVERSITY　　October.　2013

# 行政法上义务的承受研究

田宏伟[1]　王海洋[2]
(1. 商丘师范学院 法学院,河南 商丘 476000; 2. 南京大学 法学院,江苏 南京 210093)

摘　要: 行政法上义务的承受是指在义务尚未履行的情形之下,义务人死亡或者被注销,此时是消灭行政法上的义务,还是使义务发生转移,若发生义务转移即为行政法上义务的承受。行政法上的义务具有非自愿性、公共性和人身专属性的特征,不可能完全采取私法上的义务承受模式,而应当在遵循原则上不承受,例外的予以承受路径的前提下,从时效、义务承受类型法定、义务承受主体法定、程序法定入手规制行政法上的义务承受。

关键词: 行政法上义务的承受; 行政法上义务的性质; 行政法上义务承受的原则
中图分类号: D912.1　　文献标识码: A　　文章编号: 1672-3600(2013)10-0105-04

## 一、引言

案例 1: 甲因违法行为被处以 5 万元的罚款,但是甲没有按照法律规定的期限履行义务,于是行政机关决定对甲进行强制执行。在强制执行前甲死亡,留有遗产 8 万元。

案例 2: 甲因违法行为被处以罚款 200 万元,随后甲按照公司法的规定分立为乙、丙两个公司,甲公司注销。

在上述案例中,义务主体的注销或者死亡,使得未履行的义务成为"空置状态",行政目的因此而落空。但是,行政目的一般关涉公共利益,因此,在此种情况下是否允许为了行政目的的实现而承认行政法上义务的承受?

## 二、行政法上义务的性质

行政法之义务不同于私法之义务,有其独特的性质和规则。在私法领域中,意思自治或者私法自治是一项核心原则[1],该原则的要求是"自己行为,自己责任",将民事法律关系的参加者作为理性人,最大限度地尊重当事人的选择。在民事法律关系的主体平等这一框架内,配置当事人的权利和义务,同时,基于上述原则,允许私法主体基于自由意志变动当事人之间的权利义务配置,以实现资源的最优配置和满足当事人的权利诉求。因此,在私法领域,义务的性质在于其义务设定的自愿性、非公共性和非惩罚性,强制不能成为私法领域的合适手段。但是,在公法领域,强制占有重要地位,强制构成了公法领域行为模式的基础,而此种强制是依赖于法律的明确规定,如果没有明确的规定,那么其不得行动,因此,此种强制就具备正当性[2]230-231。强制的本意是忽略当事人的意志,将自己的意志强行予以实现。因此,这也就决定了公法领域的义务的品性明显地不同于私法领地,具体阐述如下。

### (一) 义务设定的非自愿性

在行政法领域,义务是否设定,何时设定,以何种方式设定并不依赖于行政法律关系的主体,而是依赖于法律的规定,即行政法上义务的设定具有强制性[3]。一旦法律规定的条件成熟,行政主体必须为一定行为或者不为一定行为,行政主体在此没有选择权。如甲在公共场所追逐、拦截他人,对他人的行为自由造成一定的妨害,那么根据《治安管理处罚法》的规定,对甲要处以五日以上十日以下的拘留,可以并处五百元以下罚款,如果有其他严重情节(如身体伤害),还要对甲加重处罚。行政主体在此种情况下没有选择的余地,只能采取行为,否则将构成行政不作为。而在给予补助的场合,一旦行政相对人处于不利境地,符合法律规定的条件,行政主体必须给予救济,也就是行政给付。对行政相对人来讲,在行政法律关系中,其利益只是在考虑的范围之内,并不构成对行政主体的强制性要求,行政主体在执行职务的过程中,可以甚至大多数情况下是忽略

收稿日期: 2013-07-30
作者简介: 田宏伟(1966-),女,河南方城人,教授、硕士,主要从事理论法学研究;
王海洋(1990-),男,河南新乡人,硕士生,主要从事宪法基本权利、行政法研究。

当事人的利益的。比如,行政合同被认为要求行政相对人予以协助,并且是对相对人的意志最为尊重的行政行为类型,但在行政合同的缔结与否以及缔结的条件上,行政相对人并没有权利要求行政主体如何行为。至于其他类型的行政行为,如行政处罚、行政强制等,行政相对人的诉求几乎对行政行为起不到任何影响。

因此,在行政法领域,义务的设定是非自愿的,它表现在行政主体和行政相对人都没有选择上。特定情境下的事实分析课以行政主体履行其职责的义务,而行政主体的行为又为行政相对人设定了义务,此类义务之设定,行政相对人必须履行,否则将发动国家公权力强制实现义务的内容。

(二)公共性

与私法领域的义务仅关涉当事人之间的利益不同,在公法领域,行政相对人之义务的实现,不仅关涉行政主体利益之实现,同时在义务的基础上还有更为重要的利益,否则强制性便没有了任何依据,因为强力并不能成为权利的基础。必须寻找更为有力的证据和理论基础,否则公法领域的行为模式建构必然是无效的。

行政法领域的行为模式是在合法性原则的基础上建构起来的。行政主体的行为必须符合法律的规定,按照法律规定的时间、程序和标准履行义务。法律被置于至上的地位,而法律是国家之公器,体现着国家的国民意志,并不为某一团体谋私利。也就是说法律是公共的、公开的。因此,作为法律执行工具的行政主体本身不能有自己的意志,其所有的只能是法律的意志。所以,公共性构成了行政法领域的超越性目标。法律构成了强力的基础,同时也使得行政法上的义务内容的实现不仅仅是与行政主体的双向关系,同时还关涉到社会利益,如社会的公平观念、社会基本结构的正义、秩序等。也就是说,公法领域的行为模式是三方利益(行政主体、行政相对人、社会)的平衡,不同于私法领域双方利益的平衡模式,同时社会利益居于首要地位。

(三)人身专属性

行政法领域的义务一般具有人身专属性,是行政主体针对特定行政相对人而为的具体行政行为。一般情形下,没有具体行政行为所指定的行政相对人的特定行为,行政行为的目的将不能达到。如,行政处罚领域的罚款即是针对特定当事人的违法行为而给予的制裁,其职能针对的是特定的违法行为人,对没有违法者不得给予行政制裁;再比如,行政给付是为救济处于特定情形下的行政相对人而出现的新的行政行为类型,特定当事人的特定情境构成了行政给付的条件等。

私法领域义务的自愿性、非公共性和非惩罚性的特征,使得义务的承受在私法领域不是问题,所以,成文法对义务的承受问题作了一般的规定,如《继承法》规定,继承人在继承被继承人遗产的范围内清偿被继承人的债务;《公司法》规定,公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继,公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。但公法领域义务的承受不仅涉及到当事人双方的利益,同时也关涉到社会利益,关涉到义务之外的惩戒目的。因此,行政法义务的承受承载着更多的价值,如果不承认行政法上义务的承受,那么将会摧毁行政法的目的。但是,行政法明显带有侵益的性质,所以,对行政法义务承受模式的选择必须在其义务性质的基础上进行。

三、行政法上义务的承受路径选择

行政法义务的性质决定了行政法上义务的承受的必要性,同时也对行政法领域义务的承受提出了基础性要求,换句话说,要按照事物的性质进行建构和归类。考究义务承受的模式,笔者认为对行政法领域的义务承受模式有两种选择:一是采取私法上的方式进行行政法上义务承受模式的建构;二是根据行政法上义务的性质,建构新的义务承受模式。

(一)私法模式

行政法脱胎于私法,是在私法成熟之后借鉴私法的规则和术语的基础上发展起来的。因此,在行政法没有规定或规定的语焉不详时,自然会寻求私法的救助,借鉴私法的规则进行行政法的重构。在私法中规定义务的承受的法律法规有《继承法》第33条,《公司法》第175条、177条,从这两部法律的规定可以看出,在私法领域,义务的承受并无限制,只要是适格的权利承受者,那么当然是义务的承受者。这是由于在私法领域,一旦成为权利的承受者,那么就意味着特定利益的获得,是获利者在其获利的范围内承担原义务的义务,并没有给权利承受者造成负担,也没有减损其法益,由其承担,并无不公正之处。

问题是行政法领域是否可以按照私法模式进行处理呢?按照私法模式进行处理,并不会对义务承受人造成负担,同时也可收简便之效,不必按照行政程序进行,按照私法程序进行即可。但是,行政法上义务的性质使得这种借鉴模式面临着诸多困境:(1)造成个案的不公正。私法的模式是在私法上义务的特性下所制定出来的指导性规范,其本身不含有义务内容之外的因素,所以只要实现义务的内容即可达到当事人建立法治序的目的。而公法在义务的实现之外还有附加的目的,如果仅仅考虑到义务

的实现而不顾义务的附加目的，那么对行政法秩序而言，法治序的目的将被挫败。如在案例 1 的场合下，针对甲的违法行为，行政机关给予 5 万元的罚款，这 5 万元的罚款不仅仅是被处罚人对国家的债务，同时也是对其违反行政法律秩序的惩罚，带有人身专属性。其留有遗产 8 万元，虽然从这 8 万元中扣除也无大碍，但是这就无形中转嫁了处罚对象，与过罚相当原则相违背，更何况继承人本身并没有违反行政法律秩序。因此，此时如果在遗产的范围内进行相应的扣减，违背行政处罚法对行政处罚的规定，属于法律适用错误应当予以撤销的行为。( 2) 造成行政行为秩序的混乱。行政行为是行政法的核心，通过行政行为，行政法律秩序得以建构，行政主体和行政相对人的权利义务得以配置。在对行政法律关系的安排中，行政主体通过具体行政行为对特定当事人的权利产生影响，即行政行为的指向是特定的，通过类型化行政主体和行政相对人，行政行为的类型得以确立，行政秩序得以建构。而义务主体的变更本身就是对这一类型化行为的对象的变更，这本身就会引起行政法律关系的变化，一定程度上会使得原有的行政行为类型混乱。如案例 1 所示，如果此时允许义务的承受，那么行政处罚行为的类型化就会造成问题，因为继承人本身并没有违反行政法律规范，而行政处罚的对象是违反行政法律规范的行政相对人。( 3) 挫败行政行为的目的。行政法领域的义务本身带有惩罚的目的，是在给予行政处罚或者其他的减损行政相对人权利之外的附加目的。通过对相对人法益的影响，引导相对人的行为向符合法律规定的方向行进。如果在义务的承受的情景之下，忽略行政行为的此项目的，那么行政行为就被挫败，行政目的就不能达到。如对被处罚人给予罚款的行政处罚，如果此时仅仅着眼于罚款的收缴，那么允许义务的承受无疑会大大促进该项目的的达成。但行政处罚的目的并不仅仅在于此，还包括教育其他国民，修复被破坏的秩序，惩戒被处罚人等。针对这样一个目的束，仅仅着眼于其中一种很显然会挫败整个的目的。

任何忽略事物性质的理论建构注定是不完善的，行政法上的义务的承受也不例外。借鉴私法模式并不能为行政法上义务的承受带来多大的助益，相反其弊反而大于利。因此，对行政法上义务的承受的模式建构，需在行政法上义务的性质的基础上进行。

( 二) 行政法上的义务承受的模式

行政法的义务具有人身专属性的特质，所谓的人身专属性指的是不可脱离义务主体而存在，一旦与义务主体相脱离，义务本身就不能存在。检视行政行为的类型，行政行为大部分是不可承受的。行政处罚在课以行政相对人罚款的目的之外还有其他的目的; 行政指导是针对特定当事人进行的劝告、建议等，旨在引导相对人实施符合行政目的的行为，因此，被引导者本身必须具备一定条件; 行政给付是对处于特定情境之下相对人的救助; 行政许可的情境之下，被许可人更不可转让其义务; 行政强制是直接针对当事人的权利的限制或者减损，以达成特定的公益之目的; 行政合同的情境之下，相对人负有按照合同履行义务的义务等。因此，行政行为的做出，是对行政相对人本身所具有的条件的信任和依赖，其所课加的义务本身必然具有人身专属性。

行政征收并未见诸上述的讨论，这是由于行政征收所具有的特殊性使然。根据理论界的通说，行政征收包括行政收费和税收。这两种行政法上的义务均不具有人身专属性，均可由他人替代履行，因为这两种行政行为并不具有义务目的之外的目的和依赖于行政相对人的特定条件。行政收费是针对享受特定公共服务的人所收的费用，“向特定的人提供的公共服务不应由全民埋单”，理应由享受利益者负担支出。行政收费这一行政行为，其本身并不蕴含更多的意蕴。税收是针对全体国民所征收的，是一种公共负担，是国民享受公共服务理应承担的支出。而针对于公共负担，负担均衡原则是一项基本的原则，不能造成一部分国民的负担过于沉重。即税收的公共性使得税收本身不具有人身专属性，税收的义务本身可以被承受。

所以，行政法上义务的承受应采纳行政法上的义务不可承受为原则，但非人身专属性的可以承受为例外的路径构建模式。( 1) 这一构建路径，是在行政行为类型化的基础上进行的。其立基于行政行为类型化本身，如根据行政处罚、行政征收、行政强制等行政行为类型化的特征进行的归纳，避免了私法模式所带来的行政行为类型的混乱。行政主体与行政相对人之间的权利义务安排得以对应化，而不是在行政相对人缺失的情况下，以已经做出的行政行为作为基础安排行政法律关系，从而导致的行政目的的混乱和行政行为类型化的缺失。( 2) 按照这一构建路径，可以避免个案不公正。在私法模式之下，由于其忽略了行政行为本身的目的和行政行为所课加的义务的特殊性质，造成不适当的权衡行政行为中的因素，忽略了行政合法性原则的要求。不同的行为具有不同的法律基础，对于行政法尤其如此，因为没有法律的授权，任何行政行为都是无效的。私法模式之下的模式建构就是没有注意到不同的法律基础所授予行政机关不同的行动范围。因此，基于正义这一法律的永恒追求，课以行政主体具

体情景具体分析的义务。(3) 采纳这一路径,可以有效地实现行政目的。不同的行政行为具有不同的目的,而在行政法领域,此种目的本身又是多样的"目的束"。在众多目的之中,附加目的并不是不重要,相反,附加目的对行政行为所指向的核心目的而言,具有辅助和扩大作用,可以将原有的目的予以最大化的实现。同时,在根据事物的性质进行行动时,其本身必然是根据事物的具体形态采取相应的措施,以实现利益的最大化。

四、行政法上义务承受的原则

行政法上的义务应以不能承受为原则,以能承受为例外。但是,对于可以承受的义务必须予以仔细地检视,由于行政法上的义务的承受是以国家强制为后盾的,国家所代表的公共利益所要求的,换句话说,其本身还是行政权力的运用。任何权力的运用都不能脱离于法律之外,必须受到法律的严格检视。因此,对行政法上义务之承受需遵守如下原则。

(一) 时效原则

时间必须是切近的,可预期的,不得在时间久远之后要求义务承受人履行义务。遥远的时间要求打破了行为人本已经建立的社会安排,破坏了行为人的预期,因此是不公正的。这就要求对义务承受人来讲,时间的要求本身是可预期的,能够保护行为人的预期利益。同时,基于信赖保护原则,行为本身的成立加上时间的因素,足以构成阻止行政主体行动的理由。

(二) 义务承受类型法定原则

行政法的义务本身是强制和无偿的,涉及公民的财产权这一宪法权利,因此,对公民宪法权利的限制只能来源于宪法或者法律而不能来源于其他[4]488。行政法规范不能成为义务承受的来源,也不能成为对国民财产权限制的依据。而行政法上义务的承受本身是对已经合法取得财产的国民的财产的剥夺和限制,并不是对原权利人财产权利的减损,因此,何种类型的行政行为确定的义务必须由法律规定。

(三) 义务承受主体法定原则

义务承受主体范围不可漫无边际,否则将会挫败法律对财产权保障的制度。义务承受主体本身的范围必须是法定的,即按照特定的标准将一定的人列为行政法上义务的"潜在履行者"。笔者主张借鉴私法的标准:享受权利者履行义务,并且以享受权利为限,而不是按照特定的亲属范围确定义务范围,因为这可能让其近亲属承受额外的负担,有失公允。

(四) 程序法定原则

行政法上义务的承受受制于行政程序的全副武装,需按照行政法程序进行,而不是按照民法上的继承程序。这是由于在相对人已经不存在的情况下,原行政决定要对新的行政相对人发生效力。而行政决定本身就是对当事人权利的减损或者限制,因此,必须让新的相对人受到行政程序的全副保护。但是,行政法上义务的承受又不同于一般的行政决定,这是由于其要将已经生效的行政决定适用于新的行政相对人,因此,决定程序可以予以省略,也就是说行政主体不必按照行政决定再作出一个跟已经作出的行政决定一样的行政决定,而是可以直接予以送达。但是,一旦当事人就事实问题提出疑问,行政主体负有予以回答和说明的义务。

五、结语

行政法上义务的承受构成了行政法领域的全新课题。其不是对现有权利者权利的减损,而是对继受其权利者的权利的减损,换句话说,是行政法上的义务是否应当有特定的人承担。根据行政法上义务的性质,对此作出的回答是:行政法上的义务一般不可承受,非人身专属性的可以继受,并且行政法上义务之承受应当受制于行政程序的全副制约,以保障行政相对人的财产权。笔者认为行政法上义务的承受对既有的行政执行体制提供了有益的借鉴,相信行政执行的实践必会继续丰富和完善这一体制。

参考文献:

[1] 迟颖. 法律行为之精髓——私法自治 [J]. 河北法学,2011(1).

[2] 边沁. 政府片论 [M]. 沈叔平,等,译. 北京:商务印书馆,1996.

[3] 雷虹,张弘. 公民在公法上的权利义务与私法上的权利义务比较研究——以行政法和民法为分析视角 [J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2012(4).

[4] 张千帆. 宪法学导论——原理与应用:第2版 [M]. 北京:法律出版社,2008.

【责任编辑:李维乐】